

1500158-42.2022.8.26.0573

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Regina Figueiredo

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... de provas quanto ao delito de tráfico de drogas, além de não restar comprovado o vínculo associativo descrito na denúncia quanto ao crime de associação para o tráfico. Subsidiariamente, pugnou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 ou, ainda, o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, a fixação do regime de aberto e o direito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

2ª Vara

Rua Ettore Targa, s/n, São Manuel - SP - cep 18650-000

1500158-42.2022.8.26.0573 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500158-42.2022.8.26.0573

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN GUSTAVO DA SILVA SANTOS JERÔNIMO e outro

Vistos.

ALAN GUSTAVO DA SILVA SANTOS JERÔNIMO e GABRIEL HENRIQUE MARQUES VERA CRUZ, ambos qualificados nos autos digitais em epígrafe, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Isso porque, no dia 22 de maio de 2022, por volta das 01h00min, na Rodovia SP 300, 286, Área Rural, nesta cidade e comarca de São Manuel, os acusados traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, 48 (quarenta e oito) eppendorfs de cocaína, pesando 11,97 gramas (massa líquida), além de 03 (três) garrafas contendo substância de Cloreto de Etila (lança perfume), drogas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão e laudo pericial provisório juntados aos autos.

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os acusados associaram-se, na forma do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, os crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006.

Os acusados foram presos em flagrante delito e o expediente policial distribuído junto ao Plantão Judiciário da 23ª CJ da Comarca de Botucatu para realização de audiência de custódia, oportunidade na qual, após as manifestações das partes, a

prisão em flagrante do acusado Alan foi convertida em prisão preventiva, bem como foi concedida liberdade provisória com a fixação de medidas cautelares ao acusado Gabriel(p.54/57).

Apresentado relatório policial final, aos dias 26 de maio de 2022 a denúncia foi oferecida, com a determinação para notificação dos acusados, regularmente cumprida nas p. 116 e 155.

Comunicação do indeferimento da liminar pretendida em sede de habeas corpus nas p.143/145.

Defesas preliminar apresentadas nas p. 123/125 e 158/160.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 29 de junho de 2022 (p.166/167).

A revisão da necessidade da manutenção da custódia cautelar do réu foi realizada às p.236/237 (CPP, artigo 316, parágrafo único, incluído pela Lei 13964/19).

Realizada audiência de instrução pelo sistema de videoconferência, conforme Comunicados e Provimentos do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em vigor ao tempo da realização dos atos processuais, oportunidade na qual foram ouvidas três testemunhas arroladas na denúncia, e interrogados os acusados, ao final, conforme gravação audiovisual juntada na p.244.

Encerrada a instrução criminal, o I. Representante do Ministério Público apresentou alegações finais orais requerendo a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia.

A seu turno, a defesa do acusado Gabriel postulou por sua absolvição sustentando a insuficiência e a fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, em caso de condenação, postulou: i) a aplicação da pena em seu mínimo legal; ii) a fixação do regime inicial como sendo aberto ou no máximo o regime semiaberto; iii) os benefícios legais previstos no artigo 44 do Código Penal, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e; iv) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Já a N. Defesa técnica do réu Alan, por meio de memoriais escritos pugnou por sua absolvição sustentando insuficiência de provas quanto ao delito de tráfico de drogas, além de não restar comprovado o vínculo associativo descrito na denúncia quanto ao crime de associação para o tráfico. Subsidiariamente, pugnou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 ou, ainda, o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, a fixação do regime de aberto e o direito de apelar em liberdade (p.245/254).

É o breve relatório.

DECIDO.

Não havendo questões de admissibilidade a analisar e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A materialidade delitativa restou suficientemente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de p.05/06, Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida de p. 14/16, Auto de Exibição e Apreensão de p. 20 e Laudo Químico-Toxicológico Definitivo de p. 170/172, que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, com resultado positivo para cocaína.

No tocante à autoria, o acusado Alan Gustavo da Silva Santos Jerônimo disse que faz apenas "bicos" e que auferia cerca de R\$800,00 a R\$900,00 por mês, declarou-se usuário de maconha e negou os fatos narrados na denúncia. Disse que estava na praça 'Tônico e Tinoco' quando seu amigo Mike passou de carro, na companhia de Gabriel e Júnior, e pegou uma carona com eles para uma festa. Próximo ao local do evento todos precisaram sair do carro, por ser rebaixado, pois tinham receio que ele não passaria pela estrada de terra e, nesse momento, uma viatura policial se aproximou e foram todos abordados e revistados, mas nada de ilícito foi encontrado em poder deles ou no veículo. Que enquanto um dos policiais foi até a viatura checar seus documentos, o outro foi até o meio do mato, cerca de dez a quinze metros, onde não havia iluminação artificial,de voltou com uma sacola plástica de mercado contendo drogas, mas não as exibiu, tampouco as garrafas, dizendo que era para um deles assumir a sua propriedade porque senão iriam todos presos, mas ninguém assumiu e todos foram conduzidos para a Delegacia. Disse que permaneceu detido com Gabriel, seu amigo de infância, por tráfico de drogas e associação, enquanto Mike e Júnior foram liberados. Negou ter dispensando algo ao chão quando a viatura policial se

aproximou, negou a propriedade das drogas e as garrafas apreendidas, bem como negou sua comercialização, juntamente com Gabriel, na festa para onde estavam indo. No mais, não sabe de quem era o dinheiro apreendido.

Já o acusado Gabriel Henrique Marques Vera Cruz disse que é usuário de maconha e que apenas cuida de sua avó, para que sua genitora possa trabalhar. Negou os fatos narrados na denúncia, alegando que estava na companhia de Mike e Júnior, quando se encontraram com Alan numa praça e lhe deram carona para uma festa, mas acabaram descendo do veículo no no caminho, porque era rebaixado e não passaria pela estrada de terra, oportunidade na qual foram abordados por policiais militares. Que foi revistado e nada de ilícito foi localizado em seu poder. Negou ter dispensado qualquer objeto quando da chegada da polícia. Que não viu os policiais localizarem qualquer objeto nas proximidades, afirmando que uma pochete contendo drogas e seu documento de identidade foi exibida somente na Delegacia de Polícia. Esclareceu que entregou seu documento de identidade para Alan guardar, pois suas vestes não tinham bolsos. Disse que no local da abordagem os policiais nada informaram sobre a localização de uma sacola contendo drogas em seu interior. Por fim, negou que pretendia comercializar as drogas apreendidas juntamente com Alan e não soube informar a origem da quantia em dinheiro apreendida pelos policiais. No mais, negou ter qualquer animosidade com os policiais, Mike ou Paulo.

Juliano Henrique Olenk Bulhoes, policial militar, declarou ter sido informado que, na noite dos fatos, haveria uma festa em uma chácara com a participação de menores e consumo de drogas, motivo pelo qual se dirigiu ao local e, ao acessar uma estrada de terra, avistou um veículo VW Golf, com quatro indivíduos parados do lado de fora. Que ao se aproximar deles, a cerca de um a dois metros, visualizou o acusado Alan dispensar em direção à rodovia uma pochete preta que segurava nas mãos, enquanto Gabriel arremessou uma garrafa que segurava no canteiro central. Após todos foram abordados nada de ilícito foi localizado em poder deles. A pochete que Alan dispensou foi apreendida por seu parceiro contendo quarenta e oito eppendorfs de cocaína, o documento de identidade de Gabriel e cerca de R\$100,00 em dinheiro. Que também foram apreendidas três embalagens de refrigerante contendo, aparentemente, lança-perfume. Os acusados esclareceram que estavam na praça 'Tonico e Tinoco', quando os outros dois indivíduos passaram de carro e ofereceram uma carona para irem todos juntos à festa. Que não conhecia os acusados dos meios policiais, porque trabalhava há pouco tempo nesta comarca.

No mesmo sentido foram as declarações do também policial militar Rafael Bergamini Grava, acrescentando, apenas, que foi realizada vistoria no interior do veículo e nada de ilícito foi localizado e que, no local dos fatos, os outros dois indivíduos que acompanhavam os acusados confirmaram ter visto eles jogando os objetos, bem como que tinham conhecimento que eles estariam portando as drogas e que iriam comercializá-las, o que eles negaram.

Por fim, a testemunha Mike Donizete dos Santos Ambrósio narrou que estava do lado de fora de seu veículo, juntamente com os acusados, mas não viu se eles dispensaram alguma coisa no chão quando a polícia se aproximou, porque foi abordado por primeiro e ficou ajoelhado de frente para a viatura. Assim também não viu os policiais localizarem no chão uma pochete e duas garrafas que eles exibiram dizendo que continham lança-perfume. Que os acusados não admitiram a propriedade desses objetos, tampouco confessaram que iriam comercializar drogas na festa para onde todos se dirigiam. Disse que desconhece o envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas, também não sabe se eles são usuários, não se recordando de ter dito que eles estavam na posse de maconha, conforme declarou na Delegacia de Polícia. Pois bem.

A cabo da instrução criminal, nota-se que a negativa de autoria sustentada pelo réu Alan em Juízo, na evidente tentativa de se isentar da responsabilidade criminal pelos fatos que ora lhes são imputados, mostra-se demasiadamente frágil e inconvincente, desprovida de qualquer adminículo probatório.

Isso porque os policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram seguros, coesos e convincentes ao relatarem, de forma uníssona, que ao se aproximarem com a viatura policial, viram Alan arremessar essa pochete contendo quarenta e oito porções de cocaína, o documento de identidade do

acusado Gabriel e outras duas embalagens pequenas contendo "lança-perfume", além de R\$100,00 em dinheiro.

Oportuno consignar que os policiais, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, são merecedores de confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer e, efetivamente, merece, até que se prove o contrário.

A respeito do tema a jurisprudência:

"É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ. [...] 8. Habeas corpus não conhecido." (HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017)." (STJ - HC: 530794 SP 2019/0261161-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 06/08/2020).

Outrossim, se o acusado Alan, por um lado, negou ter dispensado uma pochete, por outro lado, declarou que os policiais localizaram nas imediações uma sacola contendo drogas, contudo, essa sua narrativa foi refutada, tanto pelas declarações da testemunha Paulo, ainda em solo policial, quando declarou que viu Alan arremessar uma pochete para longe (p.10), como também pelas declarações da testemunha Mike, em Juízo, quando confirmou que, no local da abordagem, os policiais exibiram os objetos encontrados.

A par disso, o corréu Gabriel admitiu que entregou seu documento de identidade a Alan que, por sua vez, o guardou dentro da referida pochete, onde foi localizado, juntamente com quarenta e oito porções de cocaína, com peso líquido de 11,97g (p.50) drogas estas que não poderiam, a toda evidência, se destinar a uma só pessoa e demonstra sua destinação ao comércio a terceiros, razões pelas quais não vinga o pleito defensivo para desclassificar a infração penal descrita na denúncia para porte de entorpecentes para uso próprio, mormente considerando que ambos os acusados se declararam usuários exclusivamente de maconha e não cocaína.

Nesse sentido:

"Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação ao tráfico de drogas. (...)

Anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, o que evidencia que as drogas apreendidas eram destinadas a entrega a consumo de terceiros. Dessa forma, a quantidade de gramas era suficiente para o comércio e lesar a saúde pública" (TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000638-88.2018.8.26.0588, rel. Des. Damião Cogan, j. 17.06.2019, V.U.).

Ressalte-se que o delito em tela restou plenamente consumado ainda que o réu não tenha sido visto efetivamente comercializando drogas em virtude da pronta e eficiente ação da polícia que o prendeu em flagrante antes disso, já que o artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 prevê um tipo penal de ação múltipla alternativa, de modo que a realização de apenas uma das condutas nele descritas já é suficiente para a sua configuração, como a praticada pelo acusado de trazer consigo drogas destinadas ao consumo de terceiras pessoas.

A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.(REsp 1708569)

O mesmo não diga com relação à suposta prática do tráfico pelo acusado Gabriel, pois muito embora os policiais tenham declarado que o viram dispensando uma garrafa contendo "lança-perfume" em seu interior, o laudo pericial juntado aos autos nas p.180/184 apresentou seu resultado inconclusivo.

Além disso, o simples fato de seu documento de identidade ter sido localizado na pochete dispensada por Alan, se mostra demasiadamente frágil e precária para demonstrar, de forma segura, que ele tinha conhecimento da droga que havia no seu interior e que também iria comercializá-la.

Ressalte-se, ainda, que, relativamente ao delito do artigo 35, caput, da Lei Antidrogas, o vínculo associativo para o tráfico, de maneira estável e duradoura,

como se exige, não restou suficientemente caracterizado nos autos, na medida em que não houve campana ou uma investigação mais duradoura que demonstrasse a união de esforços e a divisão de tarefas entre os réus, sendo certo que a simples reunião esporádica, o que sequer restou demonstrado nos autos, é insuficiente para caracterizar o delito em questão.

O fato é que, nesse ponto da acusação, não se desincumbiu o Estado do ônus de comprovar cabalmente nos autos a suposta associação estável dos acusados para a prática da traficância, não se conformando o Direito Penal com menor indícios e suposições para corroborar um decreto condenatório, devendo prevalecer a máxima do princípio in dubio pro reo para que sejam absolvidos.

Assim, de rigor a parcial procedência da ação penal para o fim de condenar tão somente o acusado Alan como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42, da Lei n. 11.343/06, notadamente a primariedade técnica do acusado, conforme se observa da sua F.A de p.41/42 e certidão de p.43/44, em observância ao disposto na Súmula 444 do C. STJ, fixo a pena base no seu mínimo legal de 5(cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias multa).

Presente a circunstância atenuante decorrente da menoridade relativa do réu (p.29 e 37), contudo, deixo de reduzir a pena base em razão de ter sido fixado no mínimo legal, não poder sofrer redução aquém deste, por expressa vedação legal, consoantes o disposto na Súmula 231 do C. STJ.

Não há circunstâncias agravantes a considerar, tampouco causa de aumento de pena.

Presente a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, diante da ausência de informações acerca do trânsito em julgado da condenação anterior do acusado, além de inexistir nos autos prova de que se dedique à atividades criminosas ou integre organização criminosa, não bastando, para tanto, meros comentários de que ele era conhecido dos meios policiais.

Logo, atenta aos vetores do art. 42 da referida lei, notadamente a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes - 48(quarenta e oito) porções de cocaína, dotada de alto poder viciante e destrutivo, tenho como suficiente a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 3/5(três quintos), o que resulta em 2(dois) anos de reclusão e 200(duzentos) dias multa.

Assim sendo, torno as penas definitivas em tal patamar.

À míngua de maiores elementos sobre a situação econômica do réu e diante da sua aparente hipossuficiência, fixo no patamar mínimo o valor do dia-multa.

Deixo de proceder à detração (art. 387, § 2º, do CPP), por ser de competência do juízo da execução penal, conforme art. 66, III, 'c', da Lei das Execuções Penais e a jurisprudência do E. TJSP.

Quanto ao regime prisional inicial, observo que na decisão proferida pelo Plenário da Corte Suprema (STF - HC 118.533/MS - Rel. Min. Carmen Lúcia), entendeu-se que a figura do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº

11.343/06, não se harmoniza com a qualificação de hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e parágrafo 1º do artigo 33 do mesmo Diploma.

Muito embora possam existir respeitáveis discussões acadêmicas quanto ao mérito da referida decisão, entendo, com a devida ressalva a entendimentos contrários, que não cabe a este Juízo deixar de reconhecer força a referido precedente, igualmente adotado pela 3ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo cadastrado como Tema 600, cancelando, por consequência, a Súmula n. 512, editada em 2014.

Assim sendo, curvo-me ao entendimento jurisprudencial pacificado para reconhecer o afastamento da hediondez da conduta do acusado e, por consequência, fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, à luz do que dispõe o artigo 33, §3º, do Código Penal.

No que diz respeito à substituição da pena corporal por restritivas de direitos, apesar da recente Resolução nº 5 editada pelo Senado Federal, através da qual ficou suspensa a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", presente no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a mesma não se mostra medida suficiente e adequada no caso concreto, haja vista a postura indiferente adotada

pelo agente diante dos efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas à saúde pública e ao bem estar social, o que vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal.

Vale lembrar que os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, são cumulativos, devendo estar integralmente presentes para que seja concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o que não se verifica na espécie, sendo, portanto, inadmissível.

Deixo de fixar indenização por danos materiais em valor mínimo, pois o delito em apreço não gera efetivo prejuízo material mensurável economicamente.

Por fim, considerando o término da instrução criminal, o montante da pena aplicada a ser cumprida no regime inicial aberto, concedo ao réu Alan o benefício da liberdade provisória, a fim de que aguarde solto eventual interposição de recurso e o trânsito em julgado.

ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal em epígrafe para o fim de:

A) CONDENAR o corréu ALAN GUSTAVO DA SILVA SANTOS JERÔNIMO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o §4º, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e de 200(duzentos) dias-multa, calculados no mínimo legal; bem como para ABSOLVÊ-LO da imputação que lhe foi feita na denúncia como incurso no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se, incontinenti, alvará de soltura.

B) ABSOLVER o réu GABRIEL HENRIQUE MARQUES VERA CRUZ, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita na denúncia, como incurso no artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No mais, porque devidamente comprovada nos autos a prática do tráfico ilícito de drogas pelo réu Alan e diante da ausência de comprovação documental ou testemunhal que os valores em espécie possuíam origem lícita, declaro sua perda em favor da União (Lei 11.343/06, art.63).

Por fim, havendo aparelho celular apreendido nos autos (p.20), sem que tenha sido requerida a realização de perícia, tampouco qualquer comprovação de que era utilizado na prática delitiva ou, ainda, adquirido com recursos de origem ilícita, após eventual trânsito em julgado, mantidos os termos aqui lançados, fica, desde já, deferida a restituição, após a devida comprovação documental e com as cautelas de praxe, consoante os termos do artigo 508 das NSCGJ.

Arcará o réu Alan com as custas processuais no valor correspondente à 100 UFESP's, salvo se beneficiário da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, oficie-se para destruição das amostras guardadas para contraprova conforme o disposto no art. 525 das NSCGJ-" Encerrado o processo penal ou arquivado o inquérito policial ou termo circunstanciado, o juiz determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova, não podendo os autos serem remetidos ao arquivo sem a respectiva comunicação."

Observe-se o contido no artigo 400 das NSCGJ.

P. I.C.

São Manuel, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA